

1501499-46.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... informações dando conta do tráfico empreendido pelo réu, realizaram diligências no local. As diligências - campana - deram viva impressão do tráfico. Então, obtiveram mandado de busca e localizaram porções de "crack" e "cocaína", além de pequena quantia em dinheiro. Segundo ele, o réu afirmou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Ao ser confrontado com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501499-46.2021.8.26.0571 - Controle 2021/001628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMILTON APARECIDO ANTUNES DE CAMPOS

Data da Audiência:

15/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Ademilton Aparecido Antunes de Campos. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Ricardo Taro Kadota e José Perico Batista da Silva arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 07 horas, na Rua José Querino Vieira, nº 200, Central Park 4L, nesta cidade e comarca de Itapetininga, guardava e mantinha em depósito, para comercialização a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 0,13g (treze centigramas), e 03 (três) pedras de "crack", com peso líquido 0,50g (cinquenta centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou defesa prévia (fls. 133/136). A denúncia foi recebida em 17/12/2021 (fls. 143/145) e o acusado foi citado (fls. 164). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada

procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 13/16) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 108/112). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que as porções de drogas encontradas eram destinadas ao seu próprio consumo. Afirmou que realmente muito indivíduos frequentam sua casa para fazer uso de entorpecentes (fls. 05). Interrogado em Juízo, o réu afirmou que a droga realmente lhe pertencia, mas era destinada ao uso. Disse que as imagens captaram pessoas que consumiam drogas em sua residência, mas que não havia venda no local. Enfim, negou a traficância. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais civis receberam inúmeras denúncias anônimas (fls. 21/22) dando conta de que o indivíduo conhecido como "Mirtinho" estaria comercializando drogas. Diante disso, os policiais civis identificaram a residência do denunciado e, realizadas campanas, constataram movimentação anormal de pessoas, típica da comercialização ilícita (fls. 56), razão pela qual solicitaram a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço, o que foi deferido judicialmente nos autos nº 1505464-62.2021.8.26.0269, da 2ª Vara Criminal. Então, no dia dos fatos, os policiais civis deslocaram-se ao endereço do denunciado para cumprir o mandado de busca e apreensão e, em revista, encontraram dentro do guarda-roupa, em um pote plástico, 01 pino de cocaína e 03 pedras de "crack", além de 06 pinos vazios destinados ao acondicionamento de drogas, e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). ADEMILTON foi preso em flagrante delito. Pois bem. Agora, o policial Ricardo afirmou que após o recebimento de inúmeras informações dando conta do tráfico empreendido pelo réu, realizaram diligências no local. As diligências - campana - deram viva impressão do tráfico. Então, obtiveram mandado de busca e localizaram porções de "crack" e "cocaína", além de pequena quantia em dinheiro. Segundo ele, o réu afirmou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Ao ser confrontado com as imagens colacionadas aos autos (fls. 56), disse que era intensa a ação do tráfico na frente da residência do réu e com a presença dele. No mesmo sentido o depoimento do policial José Perico. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. As circunstâncias da apreensão das drogas, tais como as inúmeras denúncias anônimas dando conta de que o denunciado estaria comercializando entorpecentes, as campanas policiais realizadas em que foi possível verificar movimentação típica do ilícito comércio, a localização de variedade de drogas, bem como a forma de acondicionamento delas, em porções individuais, prontas para a venda, além da localização de quantia em dinheiro e de petrechos destinados à embalagem dos entorpecentes, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Ademais, foram retratadas nos autos (fls. 56). Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 25/53). Assim, na primeira fase, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda, a pena deverá ser agravada. Já na terceira fase, cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes e a recidiva. Assim, o acusado não preenche todos os requisitos legais da referida minorante. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque não está preenchido o requisito objetivo para a substituição. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. JUIZ. O ora defendido foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. A ação penal, no entanto, não merece prosperar. 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi

preso mantendo contato com pessoas, mas apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Destaca-se que, apesar da existência de denúncia, nenhum apetrecho para o tráfico foi localizado na residência do acusado e, na verdade, a apreensão realmente indica ser ele mero usuário (tanto que 6 eppendorfs vazios, indicando terem já sido usados, foram apreendidos na oportunidade). Com relação à movimentação de pessoas no local, o próprio acusado declarou que na sua casa realmente havia movimentação de pessoas, porque muitas pessoas ali iam para juntos consumirem entorpecentes, mas declarou que não vendia entorpecentes para essas pessoas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de parte das substâncias estar embalada individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal desde o primeiro momento que foi ouvido. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais.

2. DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS: Do que consta nos autos, depreende-se que não há qualquer fundamento jurídico que obste a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Mesmo que o réu seja reincidente, deve ser aplicada a causa de diminuição em questão. Em primeiro lugar, por não ser reincidente específico – as condenações anteriores são por delito contra o patrimônio e contra a vida (arts. 155 e 121 do CP). Em segundo lugar, porque deixar de aplicar a referida causa de diminuição exclusivamente em razão da recalcitrância, significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 01 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 06 (seis) anos. É evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância fática (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do non bis in idem. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo dois terços dela aplicada em função da reincidência (ou seja, por fato anterior). Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia para a dosagem da pena valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, estaríamos admitindo a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz. Pelo exposto, requer-se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3. DA DOSIMETRIA: Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou que possuía drogas; c) seja aplicada

a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º do Código Penal, tendo em vista o objetivo da norma de punir, de maneira mais branda, aquele que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida e aquele considerado “pequeno traficante” – o que é o caso dos autos; d) seja fixado regime inicial aberto e substituída a pena por restritiva de direitos; e) seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, visto não haver razões para a manutenção da prisão preventiva. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ADEMILTON APARECIDO ANTUNES DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 07 h, na Rua Jose Querino Vieira, n. 200, Central Park 4L, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de “cocaína”, com peso de 0,13 gramas, e três pedras de “crack”, com peso de 0,50 gramas. Notificado, fls. 128, o Réu apresentou defesa preliminar, cumulado com pedido de liberdade provisória, fls. 133/136, o MP manifestou-se, fls. 140/142. A denúncia foi recebida, o pedido de liberdade, indeferido, fls. 143/145 e o Réu, citado, fls. 164. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 07/09, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 10/11, no Laudo de Constatação, fls. 13/16, bem como no Exame químico-toxicológico n. 371.382/2021, fls. 108/112, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Ricardo Taro Kadota, policial civil, disse que tinha recebido várias denúncias de tráfico de entorpecentes envolvendo o Réu, e, assim, fez campanhas, durante as quais percebeu intensa movimentação típica de tráfico de drogas; com o mandado de busca e apreensão, foi à casa do Réu, onde apreendeu os entorpecentes. José Perico Batista da Silva, policial civil, disse que auxiliou no cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando houve localização das drogas. Viu as imagens feitas pelo colega e também concluiu que se tratava de movimentação típica de tráfico de entorpecentes. Ademilton Aparecido Antunes de Campos, Réu, ao ser interrogado, disse que a droga apreendida era para seu uso pessoal, e, quanto às pessoas que frequentavam sua casa, para lá iam para uso de drogas. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois, com o Acusado, houve apreensão de porções de entorpecentes em pequena quantidade, compatíveis com a destinação própria, havia poucas unidades. Não se olvida as observações policiais, durante as quais houve constatação de movimentação atípica na casa do Acusado, mas o próprio Réu disse que as pessoas frequentavam sua casa para lá usarem drogas juntamente com o Acusado, que não vendia os entorpecentes. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque foram apreendidas na sua casa, todavia, em virtude da pequena quantidade e pela dúvida acerca da movimentação atípica, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, ADEMILTON APARECIDO ANTUNES DE CAMPOS, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi

realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 15 de fevereiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA